



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעת:

קלר ציפורה
ע"י ב"כ עוה"ד ליזה זלטיין
מרחוב היען 24 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים:

1. דוד כהן
2. דבורה כהן
ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן
מרחוב יהושע בן נון 38 ירושלים

פסק דין

1. תובענה זו עניינה בבית ברחוב הטורים 21 ירושלים הבנוי על חלקה 61 בגוש 30076.
2. הבית טרם נרשם כבית משותף וזכויות בעלי הדירות רשומות בפנקס הזכויות (בבעלות וחכירות שונות).

טענות הצדדים

3. התובעת טוענת כי מאז כניסתם של הנתבעים לדירתם, לפני כ- 11 שנים, הם החלו לבצע בניה בלתי חוקית תוך השתלטות על הרכוש המשותף:

בוצעה הרחבה של דירת הנתבעים באמצעות בניית מבנה מאבן הכולל שני חדרים אשר משמשים כמטבח וחדר שינה. בניה זו בוצעה ללא הסכמת השכנים וללא היתר בניה. בגין בניה זו הוגש כנגד הנתבעים כתב אישום, נגזר דינם, ניתן ונרשם צו הריסה. במסגרת ההליכים התכנוניים הוגשו גם עררים שונים מכולם ניתן ללמוד על כי לא קיים כל היתר וממילא לא כל הסכמה לבניה של בעלי הדירות בבית;

הנתבעים התקינו שער ברזל וגדר אשר מונעים גישה לחצר ולבלוני הגז אשר מותקנים שם;

הנתבעים מונעים הנאה ושימוש בחצר המשותפת על ידי חסימת הגישה לחצר ובכלל האמור לא מאפשרים גישה לחצר ולא בניית סוכה, הכל תוך הטלת משטר של טרור על בעלי הדירות האחרים אשר כולל גם חוצפה ואלימות;

מדובר בהתנהלות שאיננה מותרת במסגרת הבית המשותף ובהתאם יש מקום לחייב את הנתבעים להשיב את מצב החצר לקדמותו ובכלל האמור להסיר את הגדרות, לפנות את החצר, לסלק ולהרוס את הבניה שבוצעה, לרבות, חיבורה לתשתיות. בנוסף עתרו התובעים באופן כללי לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש ראויים לתקופת השימוש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעים טוענים כי זכויותיהם בבית הינן של 2 דירות על פי הסכמי הרכישה והחצר הינה נספחת לדירה ובעלותם. החצר גם היתה בחזקה ושימוש ייחודיים של בעלי הדירה הקודמים להם בזכויות לאורך השנים. בפועל קיימת חלוקה מוסכמת וידועה לאורך שנים רבות.

על פי מסמכי הרכישה בבעלות הנתבעים 103.40 מ"ר כאשר שטח הדירה הינו כ- 70 מ"ר ולפיכך יתרת השטח הינה אותה מרפסת סגורה אשר נבנה בה המטבח והליכי התכנון לגביו בשלבים אחרונים.

דווקא מהדירה הנוספת בקומת הקרקע (משפחת כהן) לא היה כל פתח לחצר ומאיוור זה נכנסו בעלי הדירות לשם תחזוקת בלוני הגז. אותה כניסה נחסמה על ידי בעלי דירות אחרים והם אלו המונעים גישה – רק מאז פעולה זו החלו להיכנס בעלי הדירות דרך חצר הנתבעים.

הריסת הבניה משמעה הריסת המרפסת החוקית המאושרת של הדירה בקומה שמעל לדירת הנתבעים ואין להתיר זאת. התובעת עצמה מונעת גישה לגג המשותף. מדובר בתביעה אישית ונקמנית שכן פעולות חמורות שביצעו אחרים בבית וברכוש המשותף כלל אינם מעניינים את התובעת.

לא נעשה על ידי הנתבעים כל שינוי בגדרות כפי שהיו תמיד וגם מחסן בחצר היה קיים כל העת ובשימוש בעלי הדירות בקומת הקרקע בלבד. לא נעשה כל שינוי בחצר על ידי הנתבעים.

הליכי הרישוי מצויים בשלבים אחרונים – המטבח ממוקם בתוך מרפסת סגורה אשר שייכת לדירה וכל שבוצע הוא חיזוק ועיבוי לשם בידוד.

התובעים מטרידים ומשתמשים באלימות מילולית ופיזית וילדי הנתבעים מפחדים. משכך, בית המשפט נתן צו למניעת הטרדה מאיימת, המשטרה מעורבת ובהמלצתה הותקנו מצלמות ונקבע כי הגישה לחצר תהיה בתיאום מראש.

הנתבעים טענו עוד כי על התובעת להוכיח את זכותה המשפטית, שכן כל שבירה היא זכות שכירות בדירתה בלבד, ולא הוצגה על ידה כל ראיה לקיומן של זכויות אחרות. מטרת התביעה הינה ניסיון של התובעת לנכס לעצמה את הגג וזכויות הבניה בו.

התובעת לא השתתפה בעלויות הכרוכות באחזקת הרכוש המשותף וגם לא ביצעה דבר כנגד בעלי דירות אחרים שבנו שלא כדין וגרמו לירידת ערך לדירת הנתבעים. התובעת ובעל הדירה מתחתיה סגרו את המעבר לחצר וסיפחו אותו אליהם. התובעת סיפחה לעצמה את הגג ומונעת גישה. אין מקום להריסת המטבח ולא לניתוקו שכן זהו המטבח היחיד הקיים בדירה.

5. למען הסדר הטוב אבהיר כי כתב ההגנה הוגש על ידי הנתבעים ללא ייצוג. בהתאם אין מדובר במסמך מנוסח באופן משפטי וסדור וגם חלוקתו לסעיפים איננה ברורה. מכל מקום,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משעה שלא הוגש כתב תביעה שכנגד על ידי הנתבעים במסגרת ההליך הרי שממילא לא ניתן לתת בידם כל סעד מבין אלו שהתבקשו על ידם בכתב ההגנה ולפיכך אינני נדרש לדון בהם כלל.

6. מטעם התובעת הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידה. לתצהיר צורפה חוות דעתו של השמאי זלטיין.

7. מטעם הנתבעים הוגש תצהירה של הנתבעת.

8. ביום 09.06.16 נחקרו המצהירים נגדית ולאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.

דיון והכרעה

9. אין מחלוקת כי הבית דין עונה על הגדרתו של "בית" בסעיף 77א לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 - מדובר במבנה של קבע בו 4 דירות, קומת מחסנים והוא אינו רשום עדיין בפנקס הבתים המשותפים. בהתאם הרי שעל ניהולו של הבית חלות הוראות פרק 11 לחוק, על פיהן יש לבחון את התובענה דין. ויודגש, למעט בעלות וחכירות לא נרשם בנסח הסכם שיתוף או הערה אחרת בנוגע לחלוקת הזכויות בבית.

10. לשם הכרעה בתובענה עלינו לבחון תחילה מהו מעמדה המשפטי של החצר נושא התובענה - האם בגדר רכוש משותף, כנטען על ידי התובעת, או האם לנתבעים זכויות כלשהן בחצר זו. לשם קביעה כאמור נתייחס גם לשאלת זכויותיה של התובעת בבית.

11. לאחר קביעה כאמור נוכל להתייחס, ככל שיהיה צורך, לסעדים המבוקשים בכתב התביעה - האם זכאית התובעת לקבלת סעד המורה על סילוק יד הנתבעים מהחצר תוך בחינת השימושים המבוצעים על ידם, הריסת הבניה בדירתם ותשלום דמי שימוש.

טיב הזכויות הקנייניות

12. סעיף 77א לחוק מגדיר את ה"רכוש המשותף" בבית ככולל, בין היתר, את "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע...". "דירה" מוגדרת כ- "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, עסק או לכל צורך אחר".

13. יוצא, אם כן, כי ברירת המחדל בדין הינה כי החצר נושא המחלוקת בהליך זה הינה בגדר רכוש משותף בבית, אלא אם יוכח כי הינה חלק מ"דירה".

14. דא עקא, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי בידם זכות קניינית בחצר האמורה או כי זו הינה חלק מדירתם.

15. ראשית, טענה זו נזנחה על ידם במסגרת סיכומי הנתבעים - נפסק כבר כי זניחת טענה בסיכומים כמוה כנטישה של הטענה ודי בכך להביא לדחייתה (ר' למשל ע"א 16/89 ורדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חב' לגידול פרחים בע"מ נ' החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ, פ"ד מה (5) 729, ע"א 675/86 רבקה שמייסר נ' יצחק הודסמן, מד (1) 133 וכן י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 512).

16. שנית, גם לגופה לא עלה בידם של הנתבעים להוכיח קיומה של זכות כאמור –

הסכם הרכישה של דירתם (הוגש ביום 15.06.16 בהתאם להחלטה במסגרת ישיבת ההוכחות) מדבר על רכישת "דירה בת 3 חדרים" בלבד. אין כל אזכור לרכישת כל זכות בחצר - לא בהגדרת הממכר ולא במסגרת הוראות ההסכם;

הסכם רכישת הזכויות על ידי קודמיהם של הנתבעים בזכויות – ה"ה גרינברג, אינו כולל כל פירוט לבעלות או זכות אחרת בחצר – כל שנמכרה הינה "דירה בת שלושה חדרים" (צורף לתצהיר הנתבעת).

התשריט אשר צורף להסכם רכישת הזכויות ע"י הנתבעים (ולמעשה גם קודמיהם בזכויות) אינו כולל התייחסות לזכויות כלשהן בחצר – לא בטבלת השטחים ולא במסגרת סימון שטחי הדירה (המסומנים בתשריט בספרות 4 ו-5);

נסח הרישום אינו מגבש קיומה של כל זכות כאמור – לא במסגרת הבעלות ולא במסגרת חכירה;

17. למעלה מכל האמור הרי שמסמך רכישת הזכויות במקור מרשות הפיתוח (ע"י זליג פולק), אשר צורף גם כחלק מהסכם הרכישה של הנתבעים, מתייחס ל"דירה" כלהלן – "בקומת הקרקע בדירה בת 2 חדרים פרוזדור עם זכות המעבר בו למחזיק(ים) של חדר המסומן בתכנית במס' 4, מטבח, מרפסת, אמבטיה וב"כ משותפים עם המחזיק(ים) בחדר המסומן בתכנית במס' 4 (שתקרא להלן "הדירה") במסגרת בתכנית במס' 5 הערוכה ע"י קליינברגר והחתומה ע"י הצדדים המצורפת לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (שתקרא להלן לשם הקצור "תכנית מס' 5"), שבה הדירה מסומנת .. צהבהב וחדר אמבטיה וב"כ נוסף בקוים כחולים". אין כל אזכור לזכויות כלשהן בחצר.

18. ויודגש, אומנם חתימת מר זליג מופיעה על גבי התשריט בתחום השטח המסומן כ- "חצר". אולם, אין בכך ללמד על כי חצר זו כלולה בממכר – ראשית, החצר איננה מתוחמת בתשריט, לא מפורטת בטבלה ואיננה מוזכרת כלל בהסכם כאמור. שנית, שטר שכירות שהוגש בתיק (מוצג ת/1) מלמד כי חתימת הרוכשים בבית על גבי התשריט (גם בנוגע לדירות אחרות) נעשתה מחוץ לתחום קונטור הדירה. ברי כי רוכשי זכויות בדירה בקומה א' לא רכשו עם דירתם את הזכויות בחלל האוויר שמחוץ לדירתם.

19. זאת ועוד. לא הובאה על ידי הנתבעים כל ראיה לתמיכה בטענותיהם בדבר רכישת זכויות בחצר על ידם. כך, לא הובאו לעדות הקודמים להם בזכויות, ודאי לאור הסכמי רכישת הזכויות על ידי האחרונים. כך, ובעיקר, לא הובאה לעדות, בין בזימון ובין בתעודת עובד ציבור, כל התייחסות של רשות הפיתוח, בעלת הזכויות המקורית בבית, בנוגע לזכויות שנמכרו עוד במקור למר זליג. גם שטרי המכר או החכירה המקוריים לא הוצגו במלואם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה נעצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). מהימנעות הנתבעים להציג ראיות כאמור, ובהעדר כל הסבר להעדרן, ניתן להסיק מסקנות ראייתיות כי החצר לא נרכשה על ידי הנתבעים וגם לא על ידי הקודמים להם בזכויות בכל שרשרת העסקאות החל עוד ברכישה המקורית מרשות הפיתוח.

20. יוצא, אם כן, כי החצר הנדונה הינה בגדר רכוש משותף. אולם, בטרם נוכל לבחון את הסעדים הפרטניים המבוקשים עלינו לבחון גם את מעמדה וזכויותיה של התובעת - האם זכאית היא בכלל לנקוט בהליך דנן כנגד הנתבעים.

21. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהקשר זה אני מוצא לנכון לדחות את טענת הנתבעים כי לתובעת אין כל זכויות ברכוש המשותף לאור מעמדה כחוכרת בלבד.

22. ראשית, כמפורט בנסח הרשום לתובעת זכות חכירה לתקופה של 992 שנים בנוגע ל"דירה בקומה ראשונה המסומנת 6". אומנם, אין בידי התובעת זכות בעלות במקרקעין במקביל לזכות החכירה. אולם, סעיף 77א לחוק מגדיר "בעל דירה", בין היתר, גם כ"חוכר משנה לדורות". על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר עסקינן בחכירה לתקופה של 992 שנים כאמור. זאת ועוד. סעיף 77א לחוק גם קובע כי לצורך הוראות פרק ו' יראו גם "כל מחזיק בדירה בבית" כ- "בעל דירה". מדובר, אם כן, בהגדרה רחבה אשר התובעת, בכל מקרה, נכללת במסגרתה.

לאור החלת הוראות סעיף 57 לחוק גם על "בית" כהגדרתו בפרק ו'1, הרי שלתובעת דנן, כ"בעלת דירה" (כהגדרת החוק כאמור), גם חלק יחסי ברכוש המשותף בבית.

23. שנית, בנסיבות האמורות אין באי צירופם של בעל זכויות הבעלות (או החכירה הראשית) לגרוע מזכותה של התובעת לנקוט בהליך בנוגע לשימוש ברכוש המשותף, שגם לה זכויות בו כאמור. ויודגש, בניגוד לטענת הנתבעים בסיכומים הרי שהבעלות במקרקעין עליהם בנוי הבית איננה גוזרת בהכרח את קביעת הבעלות בדירות בבית אשר חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק - הבעלות בדירות יכולה להיות גם של חוכר לדורות כפי שהוסבר לעיל.

24. שלישית, עיון בשטר החכירה (נספח ג' לתצהיר) מלמד כי הוקנו לחוכר הראשי (ובעקבותיו גם לחוכר המשני) במסגרת התנאים המיוחדים לחכירה, למעשה, זכויות ה"בעלות" המהותיות. ודאי כאשר מדובר בחכירות (ראשית ומשנית) בלתי מוגבלות בהעברה וירשה כמפורט בנסח ולתקופות הנדונות (992 שנים!).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. רביעית, ברירת המחדל בדין הינה כי ביחד עם דירה נרכשות גם הזכויות ברכוש המשותף. האמור חל בנוגע לבית משותף רשום (סעיף 55(ב) לחוק) וביתר שאת בנוגע לבית שאינו רשום, שהרי בבית כזה ממילא כל הרכוש אשר עונה להגדרה "רכוש משותף" הינו משותף בהעדר אפשרות על פי הדין להצמיד חלקים ממנו לדירה (ר' החרגת סעיף 55 לחוק (כמפורט בסעיף 77 לחוק) בכל הקשור לבית כהגדרתו בפרק ו' 1).

כך עולה גם מהסכם רכישת הזכויות על ידי התובעת (צורף לתצהיר) שאינו מחריג במפורש או בכל דרך אחרת מכירת זכויות נלוות ברכוש המשותף. ממילא גם לא הוכח ע"י הנתבעים כי קיימת החרגה מפורשת כאמור בחכירה הראשית או החכירה המשנית של התובעת.

26. עתה ניתן לבחון את הסעדים המבוקשים במסגרת ההליך.

הריסת הבניה בדירת הנתבעים ופירוק תשתיות

27. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בהקשר זה אני מוצא לנכון לדחות את התביעה למתן הסעד המבוקש האמור.

28. ראשית, עיון בסיכומי התובעת מגלה כי היא נטשה את בקשת הסעד האמורה – כך, בסעיף 47 לסיכומים מבוקשים שני סעדים – חיוב בתשלום דמי שימוש וסילוק יד מהרכוש המשותף. הא ותו לא. אין כל אזכור, לא ברשימת הסעדים וגם לא בגוף הסיכומים, לסעד ההריסה, ודאי לא ביטוי קונקרטי כנדרש. על פי ההלכות המוזכרות לעיל, די בכך כדי להביא לדחיית התביעה.

29. שנית, גם בתצהירה של התובעת נזנח הסעד המבוקש האמור – כל שהתבקשו הם שניים – תשלום דמי שימוש ומשיכת ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף – "לאפשר לי להשתמש בו כפי שהשתמשי בו עובר לכניסת הנתבעים לבניין" (סעיף 39 לתצהיר). אין כל אזכור או בקשת סעד הריסה שחייב לקבל ביטוי קונקרטי, ברור ומפורש.

לכך התווספה, בעיקר, עדותה של התובעת במסגרת חקירתה הנגדית ממנה עלה כי כלל לא ביקשה להרוס תוספת בניה במסגרת ההליך וכי כל מטרתה בנקיטתו היתה "לרסן" כלשונה את הגב' כהן (עמוד 2 שורות 28-33).

30. שלישית, יש לדחות את התביעה בהקשר האמור מחמת השיהוי המשמעותי בהגשתה.

ההלכה קובעת כי "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 755-756; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) "ר" רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (פורסם בנבו)).

בנסיבות דנן הוכח כי תוספת הבניה בוצעה לפני שנים רבות, על פי עדות התובעת עצמה לפני 11 שנים (עמוד 2 שורה 27). אין כל הסבר מצידה של התובעת לשיהוי העצום בעצם הגשת התובענה הקניינית על ידה רק לאחר חלוף כל כך הרבה השנים. במיוחד אמורים הדברים לאור מטרתה המוצהרת בהגשת התובענה כפי שעלתה בחקירתה הנגדית (עמוד 2 שורות 28-33). לכך מתווספת העובדה כי יש בהריסת הבניה לגרום לנזק בלתי הפיך לנתבעים - מדובר במטבח היחיד בדירתם. אין די בקיומם של הליכי הפיקוח במסגרת דיני התכנון ובניה כדי להצדיק או להכשיר את ההשתתות האמורה.

31. רביעית, אין גם מחלוקת כי מעל לתוספת הבניה בדירת הנתבעים בנויה תוספת מקבילה של הדירה בקומה שמעליהם בחזקת ה"ה גולדרינג. הדברים עולים בבירור מהתמונות שצורפו לתצהירה של התובעת וגם מעדותה (ר' עמוד 3 שורה 4). עצם קבלת התביעה בהקשר האמור משמעה השפעה והשלכה ישירה גם על ה"ה גולדרינג וה"ה זיגדון, קודמיהם בזכויות אשר ביצעו את הבניה. דא עקא, האחרונים לא צורפו על ידי התובעת להליך, לא כתובעים ולא כנתבעים, ודבר לא נטען כנגדם. הם גם לא הובאו לעדות בהליך, ולכך עוד נשוב להלן.

בהתאם להלכה הפסוקה חובת תום הלב חלה גם על שכנים בבית משותף (ר' למשל ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז(4) 737, רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פד"י נה(1) 199 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרופקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו(5) 454). לפיכך, לא ניתן ליתן צו הריסה אשר משמעותו, מניה וביה, פגיעה בזכויות בעלי דירות אחרים שאינם צד להליך.

וידגש, הנטל להוכיח כי ניתן לבצע את ההריסה המבוקשת בדירת הנתבעים ללא פגיעה בבנייה שביצעו ה"ה זיגדון מוטלת על התובעת. דא עקא, היא לא הגישה כל ראיה בהקשר זה, על אף טענתם המפורשת של הנתבעים עוד בכתב ההגנה. למעשה עולה מחקירתה כי היא אפילו לא ביררה, בחוסר תום לב מובהק, מהן השלכות תביעתה להריסה בהקשר האמור (ר' עדותה בעמוד 3 שורה 5).

32. חמישית, הוכח כאמור כי בעלי הדירה שמעל לדירת הנתבעים ביצעו הרחבה דומה לזו שבדירת הנתבעים. הוכח כי שכן נוסף ביצע הרחבה בדירתו כפי שעולה מהתמונות שצורפו לתצהיר הנתבעת ואף מעדות התובעת (עמוד 3 שורה 34 ומוצג נ/2). הוכח כי אפילו בדירת התובעת עצמה בוצעו שינויים - סגירת מרפסת שירות, אף אם בוצעו לפני רכישת הזכויות על ידה (עמוד 2 שורה 25 וכן תמונות שצורפו לתצהיר הנתבעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהקשר האמור אדגיש כי מצאתי את עדותה של התובעת בלתי מהימנה – מחד היא מעידה כי בעלי הדירות האחרים בבית לא הרחיבו דירותיהם (עמוד 2 שורה 36), כי מר כהן לא ביצע כל בניה, ובלשונה - "לא עשה דבר" (עמוד 2 שורות 37) והדגשה כי קיימת "אך ורק תוספת בניה של הנתבעים" (עמוד 3 שורה 17). מאידך עולה מחקירתה הנגדית כי דירת משפחת גולדרינג הורחבה ע"י קודמיהם בזכויות (עמוד 3 שורה 4), גם השכן כהן (לצד הנתבעים) ביצע בניה (עמוד 3 שורה 34) וגם בדירתה בוצעה סגירת מרפסת שירות כאמור לעיל.

בנסיבות אלו ניתן לראות בשינויים שבוצעו בדירות האחרות בבית כ"הרחבה דומה" בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק (החל על הבית דנן בהתאם להוראות סעיף 77ב לחוק).

33. בהקשר האמור יש גם להדגיש כי התובעת לא טרחה להביא לעדות מטעמה את מי מבעלי הדירות האחרים אשר יתמוך בטענותיה, בפרט בכל הקשור לקיומן של הסכמות או אי הסכמות קנייניות להרחבת דירת הנתבעים, במיוחד כאשר, לכאורה, יש בעדותם זו לתמוך בגרסתה (ר' סעיף 21.ג. לתצהיר התובעת, מבלי לגרוע בכך שהאמור הינו בגדר עדות שמיעה בלתי קבילה). בהתאם להלכות שאוזכרו לעיל ניתן בהקשר זה להסיק מסקנות ראייתיות כנגד התובעת לפיה לא היה בעדויות השכנים כדי לתמוך בגרסתה.

34. ויודגש, דחיית התביעה כאמור הינה בנוגע לסעד ההריסה הקנייני המבוקש, ולו בלבד, ובהתייחס לשאלת הסכמת בעלי הדירות לפעולת הבניה. אין באמור להוות הכשר תכנוני ובהקשר זה נשמרות, כמובן, כל הטענות של מי מהצדדים לפעול כפי שימצא לנכון.

35. אולם, ההליך התכנוני, כשלעצמו, ודאי כאשר החלטת ועדת המשנה בנוגע לבקשת הנתבעים להיתר מפנה, בין היתר, להחלטת מפקח על רישום מקרקעין, אין בו להצדיק את קבלת התביעה (ר' במפורש החלטתה האחרונה של רשות הרישוי מיום 18.01.16 בנספח י' לתצהיר התובעת). ויודגש, לאור ההחלטה האמורה הרי שלא הוכח כי מדובר בבנייה שלא ניתן לקבל לגביה היתר בניה (כנדרש בסעיף 71א לחוק), ודאי כאשר הבניה המקבילה בקומה שמעל בנויה על פי היתר (טענה שלא חלקה עליה התובעת).

36. מכל מקום, את ההליך התכנוני, בין לקבלת היתר ובין למימוש צווי הריסה, יש להשלים מול הרשויות המוסמכות בהקשר האמור וללא כל קשר לפסק דין זה.

37. שישית, לא הוכחה כל טענה בנוגע להתחברות לתשתיות, בטח לא תשתיות פרטיות של התובעת. בהקשר האמור לא הוגשה חוות דעת מומחה כלשהי וגם לא כל ראיה קבילה אחרת. לא ניתן לבסס ממצאים ולהעניק סעדים על יסוד טענה בלבד בכתב התביעה, שממילא גם נזנחה כאמור בתצהיר התובעת (היחיד שהוגש בהליך) ובסיכומיה.

שימוש בחצר וסילוק יד

38. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי בידם זכות שימוש ייחודית בחצר, וודאי שלא זכות שימוש בלתי הדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. כבר נפסק שהסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קניינות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210). משעה שניתנה הסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

40. זאת ועוד. רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)). שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפן, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' עמ"ש 14-01-37005 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם). תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק.

41. אומנם, נטען ע"י הנתבעים כי השימוש בחצר מבוצע משך שנים, עוד לפני רכישת הזכויות בדירה על ידם. דא עקא, אין בידי הנתבעים זכויות קנייניות בחצר כאמור וגם לא ניתן לראות בשימוש המבוצע על ידם ככזה המגבש קיומה של הרשאת שימוש בלתי חוזרת – הנטל בהקשר האמור מוטל על הנתבעים אך לא הוצגה כל ראיה המבססת טענה כאמור. כל היסוד לטענה בדבר זכות השימוש עומדת על שתיקת בעלי הדירות בבית משך שנים. הא ותו לא. דא עקא, ההלכה קובעת כי על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)) - טענות הנתבעת בתצהירה אינן מקימות, אף לא בדוחק, יסודות עובדתיים להסקת מסקנה כאמור - לא הוצגה כל ראיה לקיומה של הסכמה מפורשת לשימוש ייחודי בחצר, לקיומה של תמורה כלשהי בגין השימוש, לא הוצגו תנאי ההסכמה ואף לא השקעות לכאורה של הנתבעים. מנגד הוצג מכתב אשר כולל התנגדות לשימוש האמור עוד משנת 2004 (עמוד 7 לנספח ו' לתצהיר התובעת) וכן התנגדות בהליך התכנוני העוסקת בשימוש זה בפרט (עמוד 8 לנספח ו' לתצהיר התובעת).

42. למעשה, גם טענה בדבר חלוקה בפועל משך שנים לא הוכחה בכל ראיה מצד הנתבעים, ודאי כאשר על פי גרסתם סגירת החצר על ידי בעל הדירה הנוסף בקומת הקרקע בוצעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאוחר לרכישת הזכויות על ידם (ר' עמוד 6 שורות 11-13). הטענה גם נזנחה, למעשה, בתצהירי הנתבעים (אשר התמקדו בטענת הזכות הקניינית שנדחתה כאמור) ובסיכומיהם.

43. לפיכך, אף אם ניתנה הרשאה לשימוש הרי שזו ניתנת לביטול, ודאי מעת הגשת תביעה זו, ובהתאם עלינו לבחון האם השימוש המבוצע בפועל על ידי הנתבעים בחצר הינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

44. בהתאם לדין לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

45. מן התמונות שהוצגו בפניי במסגרת ראיות הצדדים עולה תמונה של שימוש אשר חורג מגדר השימוש הסביר ברכוש המשותף –

כך, החצר מתוחמת בגדר וסגורה בשער באופן שהגישה מוגבלת וניתן אף למונעה. גם הנתבעת מאשר בעדותה כי מדובר בשער לו מפתח אשר ניתן לנעילה (עמוד 6 שורה 19).

כך, הנתבעים עצמם רואים את החצר כנכס בבעלותם בניגוד לדין (ר' למשל בעמוד 5 שורה 21). לשיטת הנתבעים עצם מתן זכות הגיש לחצר נתונה לשיקולם והחלטתם בלבד.

כך, החצר מרוצפת כמעין מרפסת לדירת הנתבעים ומונחים בה מטלטלין לרוב, לרבות, עציצים, ציוד גינה, משחקי ילדים, ציוד בניה, אופניים וכיוצ"ב.

כך, בחצר קיימים מחסנים שאין מחלוקת כי מצויים בשימוש ייחודי של הנתבעים.

46. ויוער, לא נטען כי קיימת, וממילא לא הוצגה, החלטת אסיפה כללית של בעלי הדירות אשר מתירה את שימוש הנתבעים או קובעת כללים ושימושים מותרים בבית.

47. אף אם השימושים האמורים תואמים את תנאי המקום והזמן כאמור, הרי שהם מונעים בבירור שימוש דומה מאחרים. עצם העובדה כי נדרש היה הליך שיפוטי לשם מתן זכות הגישה לשם החלפת בלוני הגז מבססת את הטענה בדבר הגבלת השימוש (ר' נפסח יא לתצהיר התובעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. ויודגש, נכון הדבר כי לדירות הקרקע ישנה, ככלל, זיקה חזקה יותר לשטח החצר לאור המיקום הפיזי של הדירה בבית. אולם, אין די בזיקה זו, כשלעצמה, כדי להקנות זכויות עודפות כלשהן שלא על פי הדין או ההלכה.

49. לאור האמור הרי שנכון יהיה לקבל את התביעה בהקשר האמור ולאסור על שימוש ייחודי בחצר. בכלל האמור יש מקום להורות על פירוק הגדרות בחצר הבית, הוצאת המטלטלין של הנתבעים מהחצר והסדרת השימוש במחסנים הממוקמים ברכוש המשותף ושלא הוכחה זכותם של הנתבעים לבדם לשימוש בהם (קניינית או בבחינת רשות שימוש בלתי הדירה כאמור).

50. למען הסר ספק לתובעת הזכות לעשות שימוש סביר בלבד בשטח החצר ואין באמור כדי להוות הכשר לכל שימוש ייחודי בחצר האמורה על ידה. לאור טיבו הפיזי של הבית, מיקום דירת הנתבעים ופוטנציאל הפגיעה בדירתם עקב שימוש בחצר הרי שמטבעם של דברים השימוש הסביר לתובעת מוגבל לתחזוקה שוטפת, שימוש במחסנים (בכפוף להחלטת רוב בעלי הדירות) והצבת סוכה בחג סוכות במקום שאינו יוצר כל הפרעה לנתבעים.

שימוש סביר על ידי התובעת בנסיבות הבית דנן אינו יכול לכלול שימוש לצורכי פנאי, ובפרט לא שימוש כזה המבוקש על ידי התובעת בעדותה (עמוד 3 שורות 19-21)!

51. לפני סיום פרק זה אבהיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בדבר "העדר מסוימות" בבקשת הסעד בהקשר האמור – ראשית, כתב התביעה הוא הקובע את גדר המחלוקת שבין הצדדים ואת הסעדים המבוקשים. במסגרת כתב התביעה נתבקשו במפורש סעדים הקשורים בסילוק יד מהחצר, פינוי מטלטלין, סילוק גדרות וכיוצ"ב (ר' סעיפים 37.1-37.5 לכתב התביעה). סעדים אלו לא נזנחו במסגרת ראיות התובעת וסיכומיה. שנית, בכל הקשור למצב החצר בעת רכישת הזכויות על ידי הנתבעים הרי שעומדות שתי גרסאות סותרות – גרסת התובעת לפיה פעולות הגידור וכיוצ"ב בוצעו על ידי הנתבעים (ר' סעיף 15 לתצהירה וכן למשל בעמוד 3 שורות 21-22). מאידך, גרסת הנתבעת כי לא בוצע דבר על ידי הנתבעים (עמוד 6 שורות 18-19). בעוד התובעת תמכה את טענותיה במכתבים וכתבי התנגדות, לרבות העובדה שאיננה שנויה מחלוקת כי הרחבת דירת הנתבעים בוצעה על ידם, הרי שהנתבעים לא הציגו כל ראיה תומכת מטעמם, ובכלל האמור לא עדות של מי מקודמיהם בזכויות שיכול היה בנקל לאשר את גרסתם. בנסיבות אלו עדיפה בעיני גרסתה של התובעת. מכל מקום, כאמור לעיל, ההכרעה מתבססת על השימוש הקיים בהתייחס להוראות הדין, בין אם בוצע לפני שנת 2003 ובין אם לאו.

דמי שימוש

52. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני מוצא לנכון לדחות את התביעה לתשלום דמי שימוש.

53. ראשית, אין לי אלא לחזור על אשר נפסק על ידי כבר בפסק הדין מיום 02.11.15 (שבוטל) – "כתב התביעה בהקשר זה אינו מפורט דיו – לא נתבע כל סכום וממילא לא צורפה כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אסמכתא לתימוכין בהקשר זה, ודאי לא לשם מתן פסק דין בהעדר הגנה כמבוקש. ויודגש, תובענה לתשלום דמי שימוש הינה תובענה כספית שיש לשום אותה, עוד במסגרת כתב התביעה. שעה שחדלה התובעת לעשות כן, וממילא גם לא שילמה אגרה מתאימה לתובענה הכספית האמורה, אין מקום לחייב את הנתבעים בדבר בהקשר זה".

54. על אף האמור לעיל לא השכילה התובעת, לאחר ביטול פסק הדין האמור, לבקש לתקן את כתב התביעה, לשום את תביעתה הכספית ולהתייחס לרכיבי הטיעון הנדרשים לביסוס העילה כפי שיפורט להלן. תשלום אגרה בלבד, ללא תיקון כדין של כתב התביעה (המקנה בדין גם זכות מקבילה לתיקון כתב הגנה) אין בו די כשלעצמו כדי להיעתר לבקשת הסעד הכללית. צודקים הנתבעים בטענתם בהקשר זה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה (ר' רציונל ונימוקים בע"א 9123/05 אדמוב פרוייקטים (89) בע"מ נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפז בע"מ (פורסם בנבו)).

55. שנית, ממילא לא עלה בידי התובעת להוכיח לגופה את תביעתה בהקשר האמור.

ויודגש, תביעה לתשלום דמי שימוש הינה תביעה כספית אישית אשר מחייבת הוכחה לכל רכיבי העילה - עצם קיומו של שימוש ייחודי שלא בהסכמה, תקופת השימוש, שווי השימוש ושיעור החלק ברכוש המשותף של התובע (על פיו זכאי הוא, לכל היותר, לתשלום).

56. אף אם נקבל את השמאות מטעם התובעת בכל הקשור לשווי השימוש (על אף הקושי האינהרנטי הקיים בהגשת חוות דעת המומחה בנסיבות דנן כמפורט בסעיפים 33 ו-42 לחוות הדעת), הרי שלא הוכחו על ידי התובעת, ולו בצל צילה של ראיה, הרכיבים הנוספים הנדרשים לשם קבלת תביעתה.

כך, לא הוכח שיעור חלקה היחסי של התובעת ברכוש המשותף. ובמה דברים אמורים. סעיף 57 לחוק קובע כי שיעור חלקו של הרכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה של דירה אל מול שטח הרצפות של כל הדירות בבית. התובעת לא הוכיחה את שטח דירתה וממילא לא את שטח הדירות האחרות בבית. ויודגש, קביעת החלק ברכוש המשותף הינה היסוד הראשוני לשם קביעת דמי השימוש להם זכאית, לכאורה, התובעת.

בהקשר זה יוער כי בסיכומיה עותרת התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום מלוא שווי דמי השימוש המוערכים על ידי השמאי - סכום שממילא לא עלה בידה להוכיח כי היא זכאית, בכל דרך, לקבלו במלואו.

כך, לא הוכח שטח החצר או הרכוש המשותף בו נעשה לטענת התובעת שימוש ייחודי, ודאי כאשר שטח זה מהווה יסוד לשומה מטעמה. בהקשר האמור לא הוצגה מפת מדידה ערוכה כדין ולא כל ראיה אחרת. גם השמאי מטעם התובעת אינו קובע שטח מדויק אלא מתבסס על הערכה בלבד וממילא לא מפרט בחוות דעתו על יסוד אילו "תוכניות" ואיזו "התייעצות" הוא מבסס את קביעתו (סעיף 3 לחוות הדעת). אין כל פירוט בחוות הדעת למסמכים אשר שימשו יסוד לעריכתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ויודגש, בהעדר כל פירוט בפרטי השכלתו של השמאי זלטיין בתחום המדידה הרי שהוכחת שטח השימוש אפשרית רק באמצעות חוות דעת מודד מתאימה, שלא הוגשה מטעם התובעת.

כך, בהיות התביעה בהקשר זה תביעה כספית רגילה, הרי שחלק ארי מהתובענה, למעשה, התיישן – השומה מתייחסת לתקופה שמחודש 01/2004 שעה שהתובענה הוגשה רק ביום 30.07.15.

כך, גם תקופת השימוש הייחודית (שהוא השימוש היחיד המקנה לכאורה זכות לקבלת דמי שימוש, אם בכלל) כלל לא הוכחה - התובעת מאשרת כי לא נמנע ממנה שימוש בחצר על פי עדותה - "היום יש לי מעבר חופשי. מי אומר שמחר היא לא תחטוף שגעון ותנעל שנית את החצר" (עמוד 2 שורה 41) בהמשך "יש לי גישה לבלוני הגז לפעמים, לפי "הג'ננה" של הנתבעים" (עמוד 3 שורות 18) ובהמשך "החצר של יעקב כהן פתוחה ונגישה. הצד השני של החצר לא כל כך נגיש" (עמוד 3 שורה 24). מאידך, לא הוצגה כל ראיה קבילה לתקופת השימוש הייחודית בעבר או תקופת מניעת השימוש מהתובעת. יוער כי בהקשר האמור התובעת מנסה להיבנות מטיעוניו של מר חווי (שלא ברורים קשריו לבית דין לאור פירוט בעלי הזכויות בבית על פי עדות התובעת עצמה בעמוד 3 שורות 14-16) בפני ועדת הערר (סעיף 21 לתצהירה). דא עקא, מדובר בעדות שמיעה בלתי קבילה שלא ניתן לבסס עליה דבר - התובעת לא טרחה לזמן לעדות את מר חווי או כל אדם אחר מטעמה לתמיכה בטענותיה.

57. זאת ועוד. לפי גרסת התובעת עצמה השימוש מבוצע משך שנים רבות, כ- 11 שנים. מאידך, לא הוצגה כל ראיה להעלאת מחאה או נקיטת הליכים משפטיים על ידי התובעת משך כל השנים. בהתאם, ולאור ההלכות שאוזכרו לעיל, ניתן לראות בשימוש שנעשה לאורך השנים כשימוש ברשות מכלל, ודאי מצידה של הנתבעת, רשות שממילא מצדיקה את דחיית התביעה לתשלום דמי שימוש לעבר (בתקופת ההסכמה מכלל).

58. לאור כל האמור הרי שגם לגופה של תביעה בהקשר האמור לא עמדה התובעת בנטל השכנוע ובנטל הראיה המוטלים עליה בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333). ויודגש, הדרך הרגילה להוכחת תביעה במישור האזרחי משמעותה היא שכאשר התובע עומד בנטל ההוכחה המוטל עליו, זוכה הוא במלוא התביעה. אולם, אם לא עולה בידי התובע להוכיח את תביעתו על פי מאזן ההסתברות, אין הוא זוכה בדבר (ר' למשל בע"א 2781/93 מ'אסה עלי דעקה נ' בית חולים "כרמל" חיפה, פ"ד נג(4) 526). כך גם במקרה דנן, ודאי בנוגע לסכום המבוקש במסגרת הסיכומים. לא הוצגו, לא התבקשו וממילא לא מתקיימים טעמים המצדיקים סטייה מן הכלל האמור בתובענה לתשלום דמי שימוש כפי זו הנדונה כאן.

סיכום

59. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

60. התביעה להריסת תוספת הבניה לדירת הנתבעים, לרבות, פירוק התשתיות, נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/305/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. התביעה לסילוק יד הנתבעים מהחצר המשותפת מתקבלת ובהתאם אני מורה כלהלן:

61.1. אני מחייב את הנתבעים לסלק כל מטלטלין מהחצר ובכלל האמור כסאות, משחקי ילדים, ציוד גינה, ציוד בניה וכיוצ"ב ולפרק את כל הגדרות והשערים בחצר שליד דירתם (למעט בהיקף שטח החלקה), לרבות, הגדר והשער בשביל הכניסה לבית וזאת בתוך 60 יום מהיום.

61.2. אני אוסר על הנתבעים לעשות שימוש ייחודי בחצר ובכלל האמור למנוע שימוש סביר מהתובעת בחצר האמורה בכפוף לאמור בסעיף 50 לעיל.

61.3. אני מחייב את הנתבעים לסלק את ידם מהמחסנים המותקנים ברכוש המשותף ובכלל האמור לפנות את הציוד שלהם המאוכסן שם וזאת בתוך 60 יום מהיום.

למען הסר ספק שימוש במחסנים יבוצע בהתאם להחלטת רוב בעלי הדירות בבית כנדרש בדין ומבלי שתישלל או תוגבל זכותו של מי מבעלי הדירות בבית לעשות שימוש סביר במחסנים כאמור.

62. התביעה לתשלום דמי שימוש נדחית.

63. לאור תוצאות ההליך – קבלת התביעה בחלקה בלבד, אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

הדברים נכונים בפרט כאשר חלקה העיקרי של התביעה על פי עמדת התובעת, בנוגע לחיוב בדמי השימוש, נדחתה כאמור.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ג' אדר תשע"ז, 01 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים